

## 第十五章 刑罚制度

### 第一节 刑罚裁量制度

#### 【考点 1：刑罚裁量概念与特点】

(1) **刑罚裁量**是人民法院在依法认定行为人构成犯罪基础上，依据犯罪事实、量刑情节与规则，决定对行为人是否判处刑罚、判处什么刑罚以及如何执行刑罚的**刑事审判活动**；

(2) 主体只能是**人民法院**，性质是刑事审判活动，前提是行为已被依法认定为犯罪；

(3) 依据是犯罪事实和各种量刑情节，内容是决定是否判处刑罚、判处什么刑罚、是否**立即执行**。

〈注意〉本书采广义说观点，狭义说过于偏狭，最广义说过于宽泛；

〈拓展〉随着犯罪圈扩大和刑罚轻缓化发展，将来可能出现更多刑事责任实现形式。

#### 【考点 2：刑罚裁量原则】

(1) 以案件事实为依据，以刑法规定为准绳，具体规定于《刑法》**第 61 条**；

(2) 案件事实包括犯罪事实、犯罪性质、情节和**社会危害程度**，需综合判断；

(3) 以刑法规定为准绳要求：依照**法定刑**量刑、根据量刑幅度情节确定适用范围、依照刑罚裁量规则适用量刑情节、依法决定免除刑罚或立即执行。

〈注意〉对社会危害程度判断不应包括主观恶性和人身危险性判断；

〈易错点〉犯罪事实和犯罪性质确定定罪，情节确定量刑幅度和具体刑罚。

#### 【考点 3：刑罚裁量情节分类】

(1) **法定量刑情节**：刑法明文规定的影响量刑的主客观事实情况，包括从轻、减轻、免除、从重处罚和量刑幅度情节；

(2) **酌定量刑情节**：刑法未明确规定但能反映犯罪危害程度和主观恶性的事实情况，主要有犯罪手段、时间、地点、对象、后果、动机、态度、一贯表现及**前科**；

(3) **应当型情节**与可以型情节：前者量刑时必须适用，后者可适用也可不适用；

(4) **从宽情节**与从严情节：前者包括从轻、减轻、免除处罚，后者仅有从重处罚；

(5) **单功能情节**与多功能情节：前者只有一种作用，后者有多种作用由法官选择。

#### 【考点 4：刑罚裁量情节适用规则】

(1) 从轻、从重处罚在法定刑限度内判处，减轻处罚在法定刑以下或下一量刑幅度内判处；

(2) 多功能情节选择适用应考虑犯罪危害程度和情节具体情况，不以排列顺序为根据；

(3) 多个同向情节并存可提升从宽或从严幅度，多个逆向情节并存先考虑从重情节再考虑从轻情节；

(4) 应当型与可以型情节并存时，应根据适用该情节确定的刑罚是否能满足惩罚和预防需要来决定。

〈注意〉不能搞“两个从轻就可以减轻”的简单相加；

〈引述〉2021 年最高法、最高检《量刑指导意见》规定同向相加、逆向相减方法。

#### 【考点 5：刑罚裁量方法】

(1) 以定性分析为主，定量分析为辅，依次确定量刑起点、基准刑和宣告刑；

(2) 量刑步骤：根据基本犯罪事实确定量刑起点→根据其他犯罪事实增加刑罚量确定基准刑→根据量刑情节调节基准刑确定宣告刑；

(3) 调节基准刑方法：单个情节直接调节，多个情节同向相加、逆向相减，特殊情节优先适用；

(4) 确定宣告刑：调节结果在法定刑幅度内可直接确定，超出法定刑范围按相应规则处理。

〈注意〉独任审判员或合议庭可在 20%幅度内调整，不符合原则的提交审委会；

〈拓展〉该方法替代了传统“估堆量刑法”，增强量刑公开性和规范性。

#### 【考点 6：累犯概念与分类】

(1) 累犯是曾因犯罪被判处一定刑罚，在刑罚执行完毕或赦免后一定期间内又犯一定之罪的罪犯；

(2) 我国累犯分为一般累犯和特别累犯两种类型；

(3) 累犯与惯犯、再犯的区别：累犯要求前罪已处罚完毕、前后罪为故意犯罪、有时间限制；惯犯以犯罪为常业、罪行未经处理、须为同种犯罪；再犯无罪名和时间限制。

〈注意〉累犯是法定从重处罚情节，表明主观恶性和人身危险性更大；

〈易错点〉累犯前后两罪都必须是故意犯罪，排除过失犯罪。

### 【考点 7：一般累犯构成条件】

(1) 行为人犯前罪时已满 18 周岁；

(2) 前罪与后罪都是故意犯罪；

(3) 前罪被判处有期徒刑以上刑罚，后罪也应判处有期徒刑以上刑罚；

(4) 后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免后 5 年内。

〈注意〉不满 18 周岁犯罪排除在累犯外，体现对未成年人教育为主方针；

〈易错点〉前罪缓刑期满不构成累犯，因为缓刑是原判刑罚不再执行而非执行完毕。

### 【考点 8：特别累犯构成条件】

(1) 危害国家安全、恐怖活动、黑社会性质组织犯罪特别累犯：前后罪均为该三类犯罪之一，刑罚种类不受限制，任何时候再犯都构成；

(2) 毒品犯罪特别累犯：前罪必须是走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪，后罪为任何毒品犯罪，任何时候再犯都构成；

(3) 特别累犯不受 5 年时间限制，体现对特定严重犯罪的严厉打击。

〈注意〉毒品特别累犯前罪范围限定为《刑法》第 347、348 条规定的犯罪；

〈拓展〉特别累犯犯后罪时间起点应为前罪刑罚执行完毕或赦免后。

### 【考点 9：自首概念与分类】

(1) 自首是犯罪嫌疑人犯罪后自动投案如实供述罪行，或被采取强制措施后如实供述司法机关未掌握的其他罪行的行为；

(2) 自首分为一般自首和准自首两种；

(3) 自首体现犯罪人接受国家审查裁判的自觉性，表明认罪悔罪态度和人身危险性减弱。

〈注意〉设立自首制度有助于分化瓦解犯罪势力、迅速侦破案件、促进犯罪人改造；

〈引述〉单位自首要求单位集体决定或负责人决定投案，如实交代单位犯罪事实。

### 【考点 10：一般自首成立条件】

(1) 犯罪嫌疑人必须自动投案：基于本人意志在归案前投案，包括经亲友规劝陪同投案等情形；

(2) 必须如实供述自己的罪行：供述的是犯罪事实、如实供述、供述自己的犯罪、供述主要犯罪事实；

(3) 共同犯罪中各共犯人应供述所参与实施并了解的整个共同犯罪事实；

(4) 犯数罪的应区分异种数罪（全部供述才全案自首）和同种数罪（交代主要犯罪可认定自首）。

〈注意〉投案后又逃跑、推翻供述、委托他人代为投案本人拒不到案等不构成自首；

〈易错点〉主要犯罪事实包括决定行为性质和影响量刑的重要事实情节。

### 【考点 11：准自首成立条件】

(1) 主体必须是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯；

(2) 必须如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行；

(3) 司法机关还未掌握应以犯罪人认识为标准判断；

(4) 本人其他罪行与已掌握罪行属不同种罪行的以自首论，属同种罪行的可酌情从轻。

〈注意〉强制措施包括拘传、拘留、取保候审、监视居住和逮捕；

〈易错点〉准自首除具备特定条件外，还应具备一般自首的主动性等要求。

### 【考点 12：坦白制度】

(1) 坦白是犯罪嫌疑人被动归案后、被依法提起公诉前，如实供述自己罪行的行为；

(2) 成立条件：主体限于犯罪嫌疑人，时间为被动归案后至起诉前，必须如实供述罪行且为主动供述；

(3) 法律后果：可以从轻处罚，避免特别严重后果的可以减轻处罚；

(4) 坦白从宽处罚应与自首拉开距离，体现自首制度的优越性。

〈注意〉被动归案包括采取强制措施、传唤到案、群众扭送三种情况；

〈易错点〉供述的罪行既可以是已掌握的，也可以是未掌握的同种罪行。

### 【考点 13：立功制度】

(1) 立功是犯罪分子到案后至判决确定前，实施检举他人犯罪、提供重要线索等有利于国家和社会的行为；

(2) 一般立功：检举揭发他人犯罪经查证属实、提供侦破其他案件重要线索、阻止他人犯罪活动、协助抓捕其他犯罪嫌疑人、其他有利于国家社会的突出表现；

(3) 重大立功：检举揭发他人重大犯罪、提供侦破重大案件线索、阻止他人重大犯罪活动、协助抓捕重大犯罪嫌疑人、其他重大贡献表现；

(4) 一般立功可从轻或减轻处罚，重大立功可减轻或免除处罚。

〈注意〉通过非法手段获取他人犯罪线索不能认定为立功；

〈拓展〉重大犯罪一般指可能判处无期徒刑以上刑罚或在省级以上有较大影响的案件。

### 【考点 14：数罪并罚概念与原则】

(1) 数罪并罚是对一人在法定时间界限内所犯数罪分别定罪量刑后，按法定并罚原则决定执行刑罚的制度；

(2) 我国采用折中原则，综合运用并科、吸收、限制加重三种原则；

(3) 吸收原则：有期徒刑吸收拘役、相同附加刑合并执行、死刑无期徒刑的并罚；

(4) 限制加重原则：相同主刑在总和刑期以下、最高刑期以上酌情决定执行刑期；

(5) 并科原则：有期徒刑/拘役与管制、主刑与附加刑、不同种类附加刑。

〈注意〉有期徒刑总和刑期不满 35 年最高不超过 20 年，35 年以上最高不超过 25 年；

〈易错点〉"酌情"应考虑数罪存在才具有的反映危害程度和主观恶性的因素。

### 【考点 15：数罪并罚适用情形】

- (1) 判决宣告前一人犯数罪：对数罪分别定罪量刑后按并罚原则决定执行刑罚；
- (2) 刑罚执行完毕前发现漏罪：对新发现罪作出判决，前后判决刑罚按第 69 条规定并罚，采用"先并后减"方法；
- (3) 刑罚执行期间又犯新罪：对新罪作出判决，前罪未执行刑罚与后罪刑罚并罚，采用"先减后并"方法；
- (4) 既有漏罪又有新罪：根据发现先后顺序分别适用相应并罚规则。

〈注意〉缓刑期间发现漏罪应撤销缓刑直接按第 69 条并罚；

〈易错点〉同种数罪是否并罚存争议，实践中多按一罪处理但缺乏法律依据。

### 【考点 16：缓刑制度概念与适用条件】

- (1) 缓刑是对被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子，在符合条件时暂缓执行刑罚，设定考验期实行社区矫正的制度；
- (2) 一般缓刑适用条件：被判处拘役或 3 年以下有期徒刑、犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险、对社区没有重大不良影响、不是累犯和犯罪集团首要分子；
- (3) 战时缓刑：战时对被判处 3 年以下有期徒刑没有现实危险的犯罪军人适用；
- (4) 对未成年人、怀孕妇女、75 周岁以上老人符合条件的必须宣告缓刑。

〈注意〉缓刑不是刑种而是刑罚运用制度，与免于刑事处罚、监外执行、假释不同；

〈易错点〉3 年以下有期徒刑指宣告刑而非法定刑。

### 【考点 17：缓刑考验期与执行】

- (1) 拘役缓刑考验期为原判刑期以上 1 年以下，但不少于 2 个月；
- (2) 有期徒刑缓刑考验期为原判刑期以上 5 年以下，但不少于 1 年；
- (3) 考验期从判决确定之日起计算；
- (4) 缓刑期间实行社区矫正，可根据犯罪情况发布禁止令；
- (5) 缓刑人员应遵守法律法规、服从监督、报告活动情况、遵守会客规定、离开居住地须批准。

〈注意〉考验期应以原判刑期为前提，不能短于原判刑期；

〈拓展〉禁止令可禁止从事特定活动、进入特定区域场所、接触特定人员。

### 【考点 18：缓刑法律后果】

(1) 考验期满无法定撤销事由的，原判刑罚不再执行；

(2) 考验期内犯新罪或发现漏罪的，撤销缓刑，前后罪刑罚按数罪并罚规定处理；

(3) 考验期内违反法律法规或监管规定，或违反禁止令情节严重的，撤销缓刑执行原判刑罚；

(4) 附加刑仍须执行，不受缓刑影响。

〈注意〉缓刑效力不及于附加刑，无论缓刑是否撤销附加刑均须执行；

〈易错点〉战时缓刑确有立功表现可撤销原判刑罚，不以犯罪论处。

## 第二节 刑罚执行和社区矫正

### 【考点 1：刑罚执行和社区矫正概述】

(1) 刑罚执行是司法机关将已生效判决所宣告的刑罚付诸实施；

(2) 减刑、假释侧重个别预防目的，量刑侧重公正报应目的；

(3) 《刑法修正案(八)》确立社区矫正制度，对管制、缓刑、假释和暂予监外执行罪犯实行社区矫正；

〈注意〉罪犯实际执行刑期必须在原判有期徒刑 1/2 以上或无期徒刑 13 年以上；

### 【考点 2：减刑的概念和适用范围】

(1) 减刑是根据罪犯服刑表现减轻刑种或减短刑期的制度；

(2) 适用范围为管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑，死刑不能减刑；

(3) 贪污罪、受贿罪死缓犯被决定终身监禁的，不得减刑；

〈注意〉死缓考验期满减为无期徒刑属于死缓制度法定变更，不属减刑；

〈易错点〉对附加刑不适用减刑，但可随主刑减刑相应变更；

### 【考点 3：减刑的条件】

- (1) 可以减刑：确有悔改表现或立功表现之一；
  - (2) 应当减刑：有重大立功表现的；
  - (3) 确有悔改表现需同时具备四个方面：认罪悔罪、遵守监规、参加教育、参加劳动；
- 〈注意〉职务犯罪等特殊罪犯不积极退赃或利用不正当手段获减刑的，不认定确有悔改表现；
- 〈示例〉立功表现包括阻止他人犯罪、检举揭发、协助抓捕、技术革新等六种情形；

### 【考点 4：减刑的限度】

- (1) 管制、拘役、有期徒刑：不能少于原判刑期  $\frac{1}{2}$ ；
  - (2) 无期徒刑：不能少于 13 年；
  - (3) 死缓期满减为无期徒刑：不能少于 13 年；
  - (4) 限制减刑死缓：减为无期徒刑不能少于 25 年，减为 25 年有期徒刑不能少于 20 年；
- 〈注意〉限制减刑死缓自死缓期满之日第二日起算；

### 【考点 5：减刑的起始时间、间隔时间和幅度】

- (1) 有期徒刑起始时间：不满 5 年执行 1 年以上，5-10 年执行 1 年 6 个月以上，10 年以上执行 2 年以上；
  - (2) 有期徒刑减刑幅度：确有悔改或立功不超过 9 个月，悔改并立功不超过 1 年，重大立功不超过 1 年 6 个月，悔改并重大立功不超过 2 年；
  - (3) 无期徒刑起始时间 2 年以上，减刑幅度 19-22 年有期徒刑；
- 〈注意〉有重大立功表现的，可不受起始时间和间隔时间限制；

### 【考点 6：应当从严掌握减刑的情形】

- (1) 职务犯罪、金融犯罪、黑社会犯罪等八类罪犯从严掌握；
- (2) 故意杀人、强奸、抢劫等暴力犯罪被判 10 年以上的从严掌握；

(3) 《刑法修正案(九)》后贪污贿赂罪原国家工作人员最严格限制；

〈注意〉拒不认罪悔罪或不履行财产性判项的，一般不予减刑；

### 【考点 7：减刑程序】

(1) 由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书；

(2) 人民法院组成合议庭审理，确有悔改或立功事实的裁定减刑；

(3) 非经法定程序不得减刑；

### 【考点 8：假释的概念和适用范围】

(1) 假释是对有期徒刑、无期徒刑犯在执行一定刑期后附条件提前释放的制度；

(2) 适用于被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子；

(3) 管制刑无假释必要，拘役刑期太短不宜假释；

〈注意〉死缓犯减为无期徒刑或有期徒刑后，符合条件可以假释；

### 【考点 9：不得适用假释的罪犯】

(1) 累犯；

(2) 故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投毒或有组织暴力犯罪被判10 年以上的；

(3) 贪污受贿死缓决定终身监禁的；

(4) 确有履行能力而不履行财产性判项的；

〈易错点〉数罪合并达 10 年以上但单罪未达 10 年的，不属禁止假释情形；

### 【考点 10：假释的服刑时间条件】

(1) 有期徒刑：已执行原判刑期 1/2 以上；

(2) 无期徒刑：已实际执行 13 年以上；

(3) 死缓犯：减刑后实际执行 15 年以上；

〈注意〉实际执行时间不包括判决前羁押期间和减刑减去的刑期；

### 【考点 11：假释的实质条件】

- (1) 确有悔改表现；
- (2) 没有再犯罪的危险；
- (3) 假释后对所居住社区没有重大不良影响；

〈提示〉可从宽掌握假释的情形包括过失犯罪、中止犯罪、防卫过当、未成年人、老弱病残等；

### 【考点 12：假释考验期】

- (1) 有期徒刑假释考验期为没有执行完毕的刑期；
- (2) 无期徒刑假释考验期为 10 年；
- (3) 假释考验期限从假释之日起计算；

〈示例〉甲判 8 年有期徒刑，执行 7 年时假释，考验期为剩余 1 年；

### 【考点 13：撤销假释】

- (1) 考验期内犯新罪：撤销假释，先减后并；
- (2) 考验期内发现漏罪：撤销假释，先并后减；
- (3) 考验期内违法但未构成犯罪：撤销假释，收监执行；

〈易错点〉考验期满后才发现考验期内犯新罪仍应撤销假释，但发现漏罪不撤销假释；

### 【考点 14：社区矫正制度】

- (1) 社区矫正对象：管制、缓刑、假释、暂予监外执行的罪犯；
- (2) 坚持监督管理与教育帮扶相结合、分类管理个别化矫正；
- (3) 社区矫正机构负责具体实施，司法所承担相关工作，检察院实行法律监督；

〈注意〉社区矫正对象在就业、就学和享受社会保障等方面不受歧视；

### 【考点 15：社区矫正监督管理】

- (1) 遵守法律法规，履行法律文书确定义务；
- (2) 定期报告活动情况，未经批准不得离开居住市县；
- (3) 实行分类管理个别化矫正，制定针对性矫正方案；

〈提示〉电子定位装置使用期限不超过 3 个月，经批准可延长；

## 第三节 刑罚消灭制度

### 【考点 1：刑罚消灭概述】

- (1) 刑罚消灭是指基于法定事由，国家对罪犯刑罚权归于消灭，包括判决确定前刑罚请求权消灭和判决确定后刑罚执行权消灭；
- (2) 刑罚请求权消灭事由：罪犯死亡、大赦、追诉期限已过；
- (3) 刑罚执行权消灭事由：罪犯死亡、刑罚执行完毕、赦免、假释考验期满、缓刑考验期满、行刑期间已过；

### 【考点 2：追诉时效概念与意义】

- (1) 追诉时效是指刑法规定的对犯罪嫌疑人追究刑事责任的有效期限，超过期限追诉权消灭；
- (2) 设立意义：时间流逝使追诉必要性和可行性降低，敦促司法机关及时追诉，维护犯罪嫌疑人权益，鼓励改过自新；

### 【考点 3：追诉时效期限】

- (1) 法定最高刑不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年；5 年以上不满 10 年的，经过 10 年；10 年以上的，经过 15 年；无期徒刑、死刑的，经过 20 年；
- (2) 法定最高刑是指与犯罪危害程度相对应的法定刑幅度的最高刑，非条文最高刑；
- (3) "不满 5 年""不满 10 年"不包括本数，"以上""以下"含本数；

〈案例〉甲故意伤害他人造成轻伤，适用法定刑幅度为"3 年以下有期徒刑"，最高刑为 3 年，追诉期限为 5 年；重伤适用"3 年以上 10 年以下"，最高刑为 10 年，追诉期限为 15 年；

〈示例〉寻衅滋事罪法定最高刑为"5 年以下"含 5 年本数，追诉期限是 10 年；

#### 【考点 4：追诉时效起算】

- (1) 追诉期限从犯罪之日起计算，犯罪之日是指犯罪成立之日；
- (2) 结果犯的追诉期限自犯罪结果发生之日起算；
- (3) 犯罪行为有连续或继续状态的，从犯罪行为终了之日起算；

〈案例〉甲 2017 年 5 月 6 日盗窃 2000 元，法定最高刑为 3 年，追诉期限 5 年，自 2017 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日；

〈示例〉挪用公款归个人使用需超过 3 个月未还才成立犯罪，自超过 3 个月未还之日起算；挪用经营活动场合从挪用之日起算；

〈案例〉甲 2017 年 5 月 6 日非法拘禁乙至 2018 年 5 月 6 日释放，追诉期限从 2018 年 5 月 6 日起算至 2023 年 5 月 5 日；

#### 【考点 5：追诉时效中断】

- (1) 在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉期限从犯后罪之日起重新计算；
- (2) 前罪在后罪之前经过的追诉期间归于无效；

〈案例〉甲 2015 年 1 月 5 日盗窃手机，追诉期限至 2020 年 1 月 4 日；甲 2018 年 6 月 3 日抢劫，盗窃罪追诉期限从 2018 年 6 月 3 日重新计算至 2023 年 6 月 2 日；

#### 【考点 6：追诉时效停止计算】

- (1) 司法机关对犯罪嫌疑人某项罪行刑事立案时，该项罪行追诉时效停止计算；
- (2) 自诉案件自被害人提起自诉之日停止计算时效；
- (3) 追诉时效计算始于犯罪成立之日，止于刑事立案或刑事自诉之日；

#### 【考点 7：追诉时效延长】

- (1) 立案后逃避侦查或审判的，不受追诉期限限制；适用条件：司法机关已立案侦查或受理案件，罪犯有逃避侦查审判行为；
- (2) 被害人在追诉期限内提出控告，司法机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限限制；

(3) 追诉时效延长与中断竞合时，适用追诉时效延长；

〈注意〉“逃避”指以逃匿方式躲避侦查审判；犯罪嫌疑人照旧在常住地生活工作不能认为有逃避行为；

〈案例〉甲 2011 年犯抢劫罪立案后逃避侦查审判，期间 2020 年又犯盗窃罪，对抢劫罪适用追诉时效延长，不适用中断；

## 【考点 8：赦免制度】

(1) 赦免是国家对犯罪分子宣告免予追诉或免除全部或部分应执行刑罚的法律制度；

(2) 我国现行宪法只规定特赦，特赦由全国人大常委会决定，国家主席发布特赦令，最高人民法院执行；

(3) 特赦是免除执行剩余刑罚或减轻原判刑罚，不是赦免罪或免除全部刑罚；

〈时序〉我国共实行 9 次特赦：前 7 次（1959-1975 年）针对战犯；第 8 次（2015 年）纪念抗战胜利 70 周年；第 9 次（2019 年）庆祝建国 70 周年；

〈案例〉2015 年特赦对象：参加抗日战争解放战争的；参加对外作战的；年满 75 周岁身体严重残疾的；犯罪时不满 18 周岁判处 3 年以下或剩余刑期 1 年以下的；

〈案例〉2019 年特赦增加对象：为国家重大工程建设做贡献获省部级以上荣誉的；现役军人获个人一等功以上的；防卫过当避险过当的；丧偶需抚养子女的女性；被裁定假释已执行 1/5 以上考验期的；

制作